

1500798-64.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... além de R\$ 30,00 provenientes do tráfico de drogas (fotografias de fls. 26/27). Ao ser entrevistado, o réu admitiu o tráfico, fato também evidenciado pela quantidade de drogas que portava, e disse que trabalhava para um tal "Luciano". 2. O processo teve trâmite regular, cf. fls. 87, 100, 117/118 e 123/124. 3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500798-64.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2148220/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 25304060 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2148220 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2148220 - DEL.POL.CHARQUEADA, 2148220/2022 - DEL.POL.CHARQUEADA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ARAUJO XAVIER DIAS

Réu Preso

Contr. nº 2022/000637

Aos 29 de agosto de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu GABRIEL ARAUJO XAVIER DIAS (PRESO CDP local). Presente o(a) defensor(a) Dra ARIANE A. DE MARINS ANDRADE. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PM Roberto Carlos Rocha Messias e PM GILMAR PEREIRA DA COSTA. Presente(s) a(s) testemunha(s) de defesa: Alexandro Aparecido Garibaldi, Lucio Cesar de Oliveira e Rafael Luis Zoppe

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa. Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per

si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s), primeiramente as comuns (PM Roberto e Gilmar), após as de defesa (Alexandro, Luciano e Rafael) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). 1. GABRIEL ARAUJO XAVIER DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processados como incurso no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 31 de maio de 2022, por volta das 17 horas e 54 minutos, na rua Silvío Sartori, na cidade de Charqueada-SP, e comarca, GABRIEL trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 129 porções de maconha (vegetal contendo THC), com massa bruta aproximada de 130,7g; e 12 eppendorfs contendo cocaína, com massa bruta aproximada de 11,8g (cf. laudo de constatação de fls. 11/13, fotografia de fls.26 e boletim de ocorrência de fls. 6/8), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. É da inicial que policiais militares patrulhavam pelo lugar indicado quando avistaram GABRIEL em atitude suspeita e esquiva. O réu foi abordado pelos servidores públicos e submetido à busca pessoal, constatando-se, assim, que ele trazia consigo, numa bolsa, 129 porções de maconha e 12 eppendorfs contendo cocaína, além de R\$ 30,00 provenientes do tráfico de drogas (fotografias de fls. 26/27). Ao ser entrevistado, o réu admitiu o tráfico, fato também evidenciado pela quantidade de drogas que portava, e disse que trabalhava para um tal "Luciano". 2. O processo teve trâmite regular, cf. fls. 87, 100, 117/118 e 123/124. 3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 6/8, depoimentos colhidos e, especialmente, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 9/10 e laudos de constatação de fls. 11/13 e toxicológico de fls. 96/98. 4. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Os PMs Rocha e Gilmar explicaram que estavam em patrulhamento pelo bairro Alvorada, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, caminhando em via pública a pé em sentido oposto ao da viatura, portando uma bolsa cor preta. Ao visualizar a viatura, o réu começou a caminhar na direção oposta, acelerando o ritmo, tentando evitar a abordagem policial. Os PMs realizaram a busca pessoal, encontrando-se na bolsa que o denunciado portava 129 porções de maconha, 12 microtubos contendo cocaína, um aparelho celular iPhone 6S e R\$30,00 em espécie. GABRIEL confessou informalmente que estava "na prática de tráfico de drogas" e que as comercializava para um tal de "Luciano". Alexandro, testemunha de Defesa, disse que quase não via o réu, mas que sabia que ele se dedicava ao trabalho. Luciano disse que presenciou a abordagem à distância de 2 quarteirões. Disse que o réu estava de bicicleta e que a recolheu após a abordagem. Não se lembrou do horário da abordagem. Rafael disse que foi à casa do réu na parte da tarde. Desceram juntos a rua. Depois de uns 10 minutos, o pai avisou que o acusado tinha sido preso. No dia dos fatos, não viu Luciano. O réu também não estava com sua bicicleta (que é de cor preta). No interrogatório policial, GABRIEL optou pelo silêncio. Em Juízo, o acusado disse que saiu de casa com sua bicicleta, depois de conversar com Rafael. Os PMs o abordaram dizendo que "sabia porque estava sendo preso", "catando pela touca". Não trazia consigo as drogas. Apesar da negativa do réu, ficou evidente, nos depoimentos dos servidores públicos, que toda a droga apreendida pertencia ao acusado e que ele se dedicava ao tráfico. Não há razão para duvidar do que disseram. De fato, nossas Cortes de Justiça avalizam os depoimentos de policiais, forte no entendimento de que seria um contrassenso cometê-los da difícil missão de atuar na prevenção e repressão de crimes para, em seguida, negar validade a seus relatos, justamente quando prestam conta em Juízo de seu sensível trabalho (sobre a validade da palavra dos policiais, cf. TJ-SP - APL: 0000162-52.2013.8.26.0547, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 06/11/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:

17/11/2014). Os depoimentos das testemunhas de defesa são divergentes e não abonam a versão do denunciado. No panorama dos autos, a condenação é de rigor. 5. No tocante à aplicação da pena, verifica-se que o réu não possui antecedentes desabonadores. No entanto, dedica-se a prática de crimes graves desde a adolescência (roubo majorado: autos nº 0000810-37.2021.8.26.0584 e 0004953-34.2020.8.26.0510 e tráfico: autos nº 0007731-57.2020.8.26.0451, cf. fls. 46 e ss.), o que, aliado à quantidade de droga, repele o privilégio. 6. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal, declarando-se perdidos bens e valores apreendidos.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: Alegações finais ORAIS gravadas por meio audiovisual.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

GABRIEL ARAUJO XAVIER DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 31 de maio de 2022, por volta das 17 horas e 54 minutos, na rua Silvio Sartori, na cidade de Charqueada-SP, comarca de Piracicaba, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 129 porções de maconha (vegetal contendo THC), com massa bruta aproximada de 130,7g; e 12 eppendorfs contendo cocaína, com massa bruta aproximada de 11,8g (cf. laudo de constatação de fls. 11/13, fotografia de fls. 26 e boletim de ocorrência de fls. 6/8), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares patrulhavam pelo lugar indicado quando avistaram Gabriel em atitude suspeita e esquiva. O acusado foi abordado pelos servidores públicos e submetido à busca pessoal, constatando-se, assim, que ele trazia consigo, numa bolsa, 129 porções de maconha e 12 eppendorfs contendo cocaína, além de R\$ 30,00 provenientes do tráfico de drogas (fotografias de fls. 26/27). Ao ser entrevistado, ele admitiu o tráfico, fato também que foi evidenciado pela quantidade de drogas que portava, além de alegar que trabalhava para um tal "Luciano".

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 100). Defesa preliminar apresentada às fls. 104/110. Após, a denúncia foi recebida (fls. 138) e o réu foi citado (fls. 117/118).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e três arroladas pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pleiteou a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 06/08;
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e fotografia de fls. 26/27;
- 3) laudo de constatação preliminar de fls. 11/13 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 96/98, os quais atestaram resultado positivo para Tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 04), o réu exerceu o direito de permanecer em silêncio. Interrogado em juízo (gravação), negou o crime. Disse que, no dia dos fatos, trabalhou até às 17 horas. Após foi para casa. Quando chegou, Rafael já estava lá conversando com seu pai. Tomou banho e, na sequência, saiu com Rafael. Saiu de bicicleta e encontrou com Luciano. Combinaram de irem à praça. Antes disso, passou em casa para avisar o pai aonde estava indo. Logo depois foi abordado pelos policiais, os quais o pegaram pela touca, por trás, jogaram-no no chão e o colocaram na viatura, dizendo que sabia o motivo pelo qual estava sendo preso.

Negou a posse de substância entorpecente. Alegou que, quando foi abordado estava junto com outra pessoa, o qual, ao avistar a polícia, saiu correndo. Por fim, disse que uma vez já tinha sido abordado pelo PM Rocha, mas nada tinha contra ele ou contra o PM Gilmar.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 02) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Roberto Carlos Rocha Messias declarou que, no dia dos fatos, estava com a equipe de Força Tática em patrulhamento de rotina pelo bairro Alvorada, na cidade de Charqueada, quando avistaram o acusado sozinho em conhecido ponto de tráfico de drogas (ali há intensa atividade de narcotráfico) caminhando na via pública, portando uma bolsa de cor preta. Disse que ele agiu de forma suspeita ao ver a viatura policial. Imediatamente, mudou de direção e passou a caminhar em sentido oposto ao da viatura, acelerando o ritmo de sua passada, aparentando claramente tentar evitar uma abordagem policial. Diante disso, resolveram abordá-lo e, no interior da bolsa que ele portava, encontraram 129 porções de maconha envoltas em papel filme, 12 microtubos de cor preta de cocaína, além de um aparelho celular da marca Iphone, R\$ 30,00 em dinheiro trocado e uma carteira com documentos. Indagado sobre as drogas, o réu confessou que eram destinadas ao tráfico, informando que as comercializava naquele local para um indivíduo conhecido pelo prenome de "Luciano", o qual coordenava o tráfico de drogas naquele ponto e foi preso alguns depois também pelo mesmo delito. Após receber ordem de prisão, o réu se agitou e foi necessário uso de algemas para ser conduzido à delegacia. Disse que, se não estivesse enganado, em patrulhamento, já tinha visto o réu na cidade de Charqueada.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 03) e sob o crivo do contraditório (gravação) pelo policial militar Gilmar Pereira da Costa, o qual esclareceu que ele próprio não conhecia o acusado, embora alguns de seus colegas já o tivessem visto.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé. O próprio réu disse que nada tinha contra ele.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O

depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra de agente público: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

A primeira testemunha arrolada pela defesa nada soube dizer sobre os fatos, pois não os presenciou, tendo, portanto, feito apenas declarações sobre a pessoa do acusado.

De fato, Alexandre Aparecido Garibaldi declarou, sob o crivo do contraditório (gravação), que a mãe do réu mora próximo de sua casa. Pouco sabe sobre ele, pois têm pouco contato. Sabe apenas que ele trabalhava como servente de pedreiro em Piracicaba.

As demais testemunhas, embora tenham tentado confirmar a tese defensiva, prestaram declarações conflitantes com a do próprio acusado e, se não bastasse, dissonantes entre si, o que retira a força de seus testemunhos, que, portanto, devem ser desprezados e não servem para infirmar os seguros e uníssonos depoimentos dos policiais.

Luciano César de Oliveira disse, em juízo (gravação), que no dia dos fatos estava na rua indo para a Praça Central de Charqueada. O réu seguia com uma bicicleta quando foi abordado por policiais, que foram ao encontro dele pela frente (o réu disse que chegaram por trás). Depois da abordagem, ele foi levado pelos policiais. O boné e a bicicleta que o réu usava no momento dos fatos ficaram jogados no chão. Disse não se lembrar se os fatos ocorreram na parte da manhã ou da tarde, bem assim o nome da rua ocorreu a abordagem, apesar de morar na pequena cidade de Charqueada

há 3 anos. Alegou que, no momento dos fatos, estava na rua de sua casa, que não era a Rua Silvia Sartori. Estava na esquina, numa lanchonete. Estava combinando com os amigos de irem para a praça. No momento da abordagem, o réu estava a dois quarteirões de distância. Não conhece nenhum traficante de nome Luciano.

Por sua vez, Rafael Luís Zoppe declarou, em audiência (gravação), que, no dia dos fatos, por volta de 17,30 horas, foi à casa do réu, onde o encontrou. Ficaram dentro da casa dele conversando por aproximadamente meia hora. A casa dele ficava na rua Silvio Sartori, três ruas para cima da sua. Depois, saíram juntos. Foi em direção à sua casa. O réu partiu em direção à casa de um colega. Depois de uns 10 minutos, o pai dele chegou em sua casa nervoso, dizendo que ele havia sido preso. Conhece a testemunha Luciano, mas não o viu no dia da prisão. O réu não tem motocicleta. Ele tinha uma bicicleta preta, mas ele não estava de bicicleta no dia dos fatos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que, para fins de mercancia, o réu trazia consigo as substâncias descritas na denúncia, as quais determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De fato, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido de que, em patrulhamento de rotina pelo local, depararam-se com o acusado caminhando a pé em região conhecida como ponto de tráfico e notaram que, ao perceber a presença da viatura, ele, que portava uma bolsa, agiu de forma suspeita, passando a caminhar em sentido oposto ao que vinham e acelerando o ritmo de sua passada, tentando evitar uma abordagem policial, atitude típica de quem está cometendo crime.

Na sequência, ele foi abordado e, na revista pessoal, foram encontrados em seu poder 129 porções de maconha e 12 microtubos de cocaína, os quais estavam acondicionados no interior da bolsa que ele portava (fotografia de fls. 26/27).

Ademais, ao ser indagado sobre as drogas, ele não só confessou informalmente que estava traficando, como também revelou que trabalhava para um indivíduo conhecido pelo prenome de "Luciano", que coordenava o tráfico de drogas no local e, segundo os policiais, foi preso poucos dias depois também pelo narcotráfico.

Registro que não só as circunstâncias da diligência, mas também a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes que o réu trazia consigo confirmam o destino mercantil, pois incompatíveis com a situação de mero usuário.

Some-se a isso o fato de os entorpecentes estarem embalados na forma como comumente são comercializados, bem como o fato de ser apreendida quantia em dinheiro (R\$30,00), em notas trocadas, o que, aliado à falta de comprovação idônea por parte da Defesa, da origem lícita do dinheiro, faz presumir decorrer do comércio ilegal e confirma o destino mercantil dos entorpecentes, ensejando, inclusive, seu perdimento para a União.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não esbanja a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO."

(TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a

presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é primário e possui bons antecedentes (cf. F.A. de fls. 84 e certidão de fls. 89/90).

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

A quantidade de drogas, embora mais expressiva a ponto de indicar o tráfico, não fugiu à normalidade da espécie.

Assim, aplico-lhe as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

As atenuantes, como menoridade e confissão, não autorizam a redução das penas aquém do mínimo legal.

Não há agravantes.

Inexistem causas de aumento.

Não estão presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu, embora primário, possui condenações na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos aos delitos de roubo e receptação (fls. 48 - com medida de internação), bem assim de tráfico de drogas (fls. 52 - medida de liberdade assistida), o que, aliado ao fato de não ter comprovado satisfatoriamente exercer atividade lícita e trazer consigo expressiva quantidade e diversidade de drogas, demonstra que vem se dedicando às atividades criminosas, dentre elas o narcotráfico, atividade que fazendo como seu meio de vida.

Tal fato demonstra que o réu tem total desprezo pela lei e pela justiça e, mesmo depois que atingiu a maioridade penal, continuou traficando.

Trata-se, portanto, de traficante que vem reiterando nas atividades criminosas, não se podendo equipará-lo aos pequenos e eventuais traficantes.

Registro que a aplicação da minorante exige a existência cumulativa dos quatro requisitos presentes no dispositivo supramencionado, quais sejam: a) agente ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.

Conforme exposto acima, o réu não preencheu todos esses requisitos, tendo se

dedicado às atividades criminosas desde a adolescência, não comprovando atividade lícita, além de trazer consigo expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. No sentido de que, em casos como esse, é incabível o privilégio, já se manifestaram as duas turmas do C. STJ:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. PATAMAR DE ELEVÇÃO. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Assentado pela instância antecedente que o paciente se dedica a atividade delitativa, uma vez que possui medidas socioeducativas em fase de execução, inclusive pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para se afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 5. Segundo posicionamento deste Tribunal Superior, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades. 6. Concluído pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas provas colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu nas proximidades dos locais previstos no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, a pretensão de afastá-la demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". (Precedentes). 8. Hipótese em que o Tribunal de origem majorou a pena na fração de 1/5, tão somente pelo fato de terem sido reconhecidas 2 majorantes (art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006), impondo-se, portanto, o redimensionamento para a percentual mínimo (1/6). 9. Fixada a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, sendo primário o réu e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 10. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração das majorantes para 1/6, ficando a reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão, bem como para fixar o regime inicial semiaberto." (HC 529.996/SP, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 12/11/2019). g.n.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). NÃO

APLICAÇÃO. PASSAGENS ENQUANTO MENOR. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. PENA TOTAL SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE ABSTRATA E HEDIONDEZ DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO ELEVADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicá-la ao caso concreto em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pelo fato do paciente ostentar passagens anteriores enquanto menor de idade, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça. Ademais, para se acolher a tese de que o paciente não se dedica à atividade criminosa, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus. 3. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo, de acordo com o disposto no enunciado n. 440 da Súmula desta Corte e os enunciados ns. 718 e 719 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal - STF. 4. Sedimentou-se, ainda, o entendimento segundo o qual, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º, do Código Penal em conjunto com o art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. In casu, resta evidenciado o constrangimento ilegal na imposição do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, a fixação foi em razão da hediondez e da gravidade abstrata do delito, o que vai de encontro com a jurisprudência desta Corte Superior, mormente se considerarmos que a quantidade de droga apreendida não foi elevada (uma porção de maconha com peso de 39,16g). Dessa forma, considerando, ainda, que o paciente é primário, bem como o quantum de pena aplicado (5 anos de reclusão), correta a fixação do regime semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 5. Mantida a pena fixada pelas instâncias ordinárias superior a 4 anos, o pleito quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra-se prejudicado, haja vista que o paciente não preenche os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento inicial da pena do paciente". (HC 512.197/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 06/08/2019).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 1. Diz o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o paciente seja primário, portador de bons antecedentes, não integre organização criminosa nem se dedique a tais atividades. 2. As instâncias ordinárias afastaram, fundamentadamente, a incidência da benesse pretendida sob o fundamento de que as circunstâncias que ladearam a prática delitiva evidenciam a dedicação do paciente à atividade criminosa. 3. Destacou a sentença que o paciente, além de haver sido preso com considerável quantidade de cocaína - 35 (trinta e cinco) invólucros plásticos - em conhecido ponto de venda de entorpecentes, fazia "do crime seu meio de vida", não comprovando o exercício de qualquer atividade lícita e já ostentando registro anterior na Vara da Infância e Juventude por ato infracional equiparado a tráfico de drogas. 4. Indeferida a aplicação do redutor de pena com base em motivação idônea, inviável se torna, na via do writ, o revolvimento de provas com o fim de verificar a justiça da decisão. 5. O regime semiaberto é o recomendável, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o paciente é primário, e a reprimenda não ultrapassa o patamar de oito anos

(Súmula nº 440 do STJ). 6. Ordem parcialmente concedida". (HC 212.704/SP, Sexta Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, j. em 15/09/2011). Incabível, assim, o privilégio.

Quanto ao regime de pena, rendendo-me ao posicionamento das duas Turmas do C. STJ, conforme julgados supracitados, deixo de fixar o fechado e elejo o semiaberto, eis que a quantidade de droga, embora expressiva a ponto de revelar o tráfico, não é, por si só, indicativa de crime de maior relevância ou de se tratar de traficante de grande envergadura. No entanto, a pena é superior a quatro anos e inferior a oito e, por outro lado, conforme exposto, o réu vinha reiterando nas atividades criminosas, o que justifica a eleição do regime intermediário.

Ademais, o crime de tráfico de drogas tem graves consequências, fomentando a prática de vários outros delitos, destruindo famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Necessária, assim, a fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de sua substituição por penas restritivas de direitos, as quais também são incompatíveis com a quantidade de pena imposta.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato e, considerando que já vem traficando há algum tempo, desde que era menor de idade, muito provavelmente continuaria a realizar o nefasto comércio.

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas dois meses e vinte e oito dias, não tendo, ainda, preenchido requisito objetivo para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu GABRIEL ARAUJO XAVIER DIAS a cumprir cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida em poder do acusado (R\$ 30,00) é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Conforme acima exposto, o réu possui envolvimento pregresso com a prática de atos infracionais análogos ao roubo, a receptação e ao tráfico de drogas e, ao atingir a maioridade, continuou a exercer o nefasto comércio ilícito, tanto que trazia consigo considerável quantidade e variedade de drogas, tudo, pois, a indicar maior periculosidade e real possibilidade de reiteração criminosa.

Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual é necessária para garantia da ordem pública e fica, assim, mantida.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhida, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MINISTÉRIO PÚBLICO foi dito que se manifestaria no prazo legal.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Saem as partes cientes da sentença proferida e do prazo para oferecimento de eventuais recursos. Recebo o recurso interposto. Desde já sai a defesa intimada do prazo para apresentação das razões de apelação, independentemente de nova intimação, uma vez que trata-se de processo digital e o recurso foi recebido neste momento. Regularize-se o sistema informatizado. Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.